

1523277-68.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523277-68.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523277-68.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LAIS GONCALVES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

LAIS GONÇALVES PEREIRA (RG: 38680225) foi denunciada como incurso no artigo 33, caput e §1º, inciso I, ambos da Lei n 11.343/06, combinados com o art. 61, inciso II, alínea j do Código Penal (calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19):

porque, na data de 05 de novembro de 2020, durante período de calamidade pública, por volta das 06h00, na Rua Major José Lopes, número 4-C, Grajaú, nesta cidade e comarca, teria mantido sob sua guarda e depósito 1.000 (mil) invólucros, contendo 608,4 gramas de cocaína, e 08 (oito) sacos, contendo 6.640 gramas da mesma droga, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e

porque, nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada teria mantido sob sua guarda e depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (dois) sacos que continham 2001,8 gramas de lidocaína, além de 04 (quatro) sacos contendo 84,7 gramas de cafeína, matérias-primas destinadas à preparação de drogas.

A acusada foi presa em flagrante (fl. 4) e o juízo de plantão homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva (fls. 97/100).

O juízo natural, nos termos do artigo 316, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória à acusada, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 216/220).

O alvará de soltura foi expedido e cumprido (fls. 221/224 e 237/241).

A ré foi regularmente citada e notificada (fls. 236) e apresentou defesa preliminar (fls. 251/259).

A denúncia foi recebida (fls. 265).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e, ao final, a acusada foi interrogada.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com exasperação inicial da pena, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de regência, e a fixação do regime fechado.

A defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição relativa ao artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06; a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os policiais civis José Carlos Ferreira da Silva e José Carlos de Andrade afirmaram extrajudicialmente que são componentes da equipe Falcão 17 e que no dia 30/09/2020 apreenderam grande quantidade de drogas ilícitas no imóvel situado na Rua Cinco, número 28, casa 01, no bairro Jardim Monte Verde, conforme RDO nº 61/2020, tendo como investigada LAIS GONÇALVES PEREIRA e outros. Aduziram que, com base no relatório de investigação, a Autoridade Policial representou pleiteando autorização judicial para fins de busca e apreensão criminal em imóveis onde seriam entregues drogas e valores e que, naquela data, diligências foram encetadas com o fito de dar total e fiel cumprimento a um dos mandados expedidos, tendo como alvo o imóvel situado na rua Major José Lopes, número 4-C, Jardim Shangrilá, São Paulo/SP.

Relataram que, na ocasião, foram recebidos por LAIS GONÇALVES PEREIRA, a qual, ciente do mandado de busca e apreensão, franqueou a entrada na casa, acompanhando as buscas realizadas. Narraram que, ao ser indagada quanto à existência de drogas ilícitas no imóvel, a investigada negou, contudo, em um rack da sala, acabaram por localizar uma mala no interior da qual estava acondicionada grande quantidade de sacos plásticos contendo substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína, bem como um saco contendo substância acinzentada e uma balança, e, dada continuidade às buscas, localizaram, no porta-malas do veículo de placas PVN 1956/SP (VW/UP TAKE MA), estacionado na garagem, mil (1000) invólucros plásticos contendo a droga cocaína, já fracionados e embalados para à venda. Afirmaram que, ao ser indagada ainda no imóvel, LAIS disse que tanto a casa quanto o carro seriam de seu primo Mikon Sousa Bispo, negando responsabilidade pelas substâncias localizadas.

Em juízo, o policial José Carlos de Andrade narrou que receberam uma denúncia anônima, foram checar e, ao chegarem no local, havia pessoas na frente, já que era uma vila, com famílias residindo em casa diferentes. Relatou que, questionando a primeira testemunha, esta deixou entrar e a porta da casa onde ocorreu a apreensão estava aberta, então eles entraram e encontraram drogas, balanças, documentos.

Aduziu que deram continuidade às investigações e, com um mandado de busca e apreensão, encontraram as demais drogas. Explicou que na primeira diligência, em que as portas estavam abertas, havia documentos pessoais da ré e do filho, se não se engana, até contrato de aluguel, e os vizinhos optaram por não falar se ela era traficante, mas confirmaram que ela morava ali; já na segunda, a realizada com mandado de busca, disse que não lembra como chegaram no endereço, e acha que foi por causas de algumas anotações encontradas no primeiro endereço. Confirmou que participou da segunda diligência, com o mandado, e informou que, se não engana, só tinha uma criança com a ré, o seu filho, e que foram apreendidas drogas diversas, em grande quantidade, não se lembrando de quais tipos. Afirmou que também havia uma esteira quebrada e materiais para preparo de drogas, bem como anotações de

contabilidade, não se lembrando se era um caderno. Asseverou que tinha um veículo na garagem, um Volkswagen Up, da cor branca, que estava aberto, e no porta mala havia mais um saco de drogas, pronto para venda. Falou que a ré não tinha a chave do carro, dizendo que um primo tinha deixado o carro ali, e o veículo acabou sendo guinchado. Disse que a ré informou que o primo era envolvido com o crime organizado, e como era muito amiga do primo, acabou se envolvendo para ajudá-lo. Respondeu que tinha conhecimento de um tal Maicon na primeira diligência, e não se lembra de algo relacionado a ele ter sido encontrado.

Em juízo, a testemunha policial José Carlos Ferreira da Silva narrou que participou das duas diligências e que, na primeira, havia o informe de uma denúncia e se dirigiram até o local, onde ficou por uma semana monitorando e num certo dia visualizaram um casal (ou apenas uma pessoa, não se lembra bem), que deixou ele entrar naquele lugar, já que era uma vila com várias portas, então revistaram alguns imóveis com autorização dos moradores e o casal também foi levado à delegacia. Contou que a porta da última casa estava aberta, da onde saía um forte odor e em seu interior encontraram várias drogas, uma balança, faca com resquício, liquidificador e documentos pessoais dela e do filho. Aduziu que o casal informou que direto passavam motocicletas ali para pegar alguma coisa da casa dela. Relatou que continuaram a investigação e descobriram o endereço dela, que ficava perto, a cerca de 2 km, e conseguiram um mandado de busca. Declarou que lá também havia várias casinhas e na última de cima, a ré, que estava dormindo, abriu a porta e, embaixo do rack da televisão, foi encontrada cocaína em sacos. Informou que na garagem havia um veículo Up, cujo porta-malas não estava trancada, e encontraram mais drogas fracionadas. Disse que ela estava dormindo com o filho, uma criança de 8 a 10 anos. Aduziu que ela alegou que o carro era do primo, que ambos eram muitos próximos e ele a ajudava financeiramente. Respondeu que não lembra de utensílios nem de materiais para produção encontradas nessa segunda diligência, e também não sabe confirmar, mas acha que tinha o nome de Maicon na denúncia anônima, assim como não sabe se tinha o nome da ré nessa denúncia. Falou que também não lembra se no mandado de busca constava o nome dela, assim como não se lembra se foi apreendido um contrato de locação.

Em seu interrogatório extrajudicial, a acusada LAIS GONÇALVES PEREIRA, assistida por seu advogado Sérgio Aparecido da Silva (OAB/SP 285.978), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, a ré negou que tenha acontecido da forma denunciada. Disse que além de primo, teve um caso amoroso com Maicon, e tinha se afastado dele em torno de um mês antes, por causa de brigas, e não estava mais morando na residência, porém não teve tempo para retirar todos os seus documentos de lá, pegou somente seu RG e seu filho. Alegou que, ao ocorrer a primeira diligência, seu primo a procurou e, como ela estava se sentindo coagida com o ocorrido, ela foi até ele para conversar, acompanhada do filho. Informou que os policiais chegaram ao local chamando por ele, não estava procurando por ela, e depois de ela informar seu nome, os policiais lhe disseram que ela estava sendo investigada, e ela justificou que tinha ciência, mas que não tinha responsabilidade porque a droga não era dela, e que a casa era de Maicon, tanto que foi encontrado um comprovante de pagamento de aluguel em nome dele, assim como um título de eleitor dele e documentos dele, na segunda casa, já que na primeira casa foi o dela. Falou que a segunda casa era dele e ela foi lá só para conversar, e conversaram durante a madrugada, estavam tentando reatar, e ela acabou dormindo lá. Aduziu que ele saiu mais cedo e trocou o carro, pois ele tinha um carro preto e não branco, inclusive falou isso aos policiais, que se fosse tal carro seria do primo, e disse a eles que não tinha conhecimento sobre as drogas apreendidas dentro do veículo. Falou que não tinha bens dela na casa, nem roupa, tanto é que estava usando uma roupa do primo, uma camiseta. Admitiu que sabia que ele provavelmente tinha envolvimento com drogas, porém ela não tinha nada a ver com aquilo. Perguntada se ela tinha visto a localização de drogas dentro da casa, respondeu que lembra de ter sido encontrado um caderno, e que a droga estava dentro do porta mala do carro. Asseverou que pediam a chave do carro para ela, mas ela dizia que não tinha chave, pois não sabia dirigir e que a casa não era dela, assim como o carro dele era um preto. Informou que lembra de os policiais terem levado os

documentos do primo, um título e dois recibos de aluguel. Alegou que não morava mais na casa, pois já estava morando com a mãe desde que aconteceu aquilo na primeira casa, pois eles tinham se desentendido, e tinha ido para a segunda casa, na véspera da busca, para se reconciliar e foi até com o filho. Repetiu que já tinha saído da primeira casa um mês antes, e já tinha retirado o RG, a única coisa que conseguira retirar quando teve um desentendimento com o Maicon, e acha que só foi encontrado uma carteira de trabalho antiga e o seu título. Contou que ele não morava diretamente com ela, só dormia às vezes aos finais de semana e pagava as contas, porém quando ele começou a frequentar mais, e houve o desentendimento, ela foi embora e, como ele tinha responsabilidades com as contas, a casa ficou com ele. Informou que, entre 2 semanas e 1 mês depois da primeira diligência, ela foi conversar com ele para tentar a reconciliação e para conversar sobre o que estava acontecendo, pois ela estava sendo investigada por algo que ela não fez, razão pela qual foi até à segunda casa, que ele tinha alugado. Explicou que a primeira casa, ela começou morando sozinha com o filho, porém, quando houve a diligência, ela já não estava mais lá havia um mês ou mais, e a porta não estava aberta, estava arrombada, pois ela tinha ido embora sem dar satisfação, pegando apenas o que pôde pegar. Repetiu que tinha conhecimento do envolvimento dele com drogas, pois não é boba, via, mas não tinha envolvimento, não participava. Disse que o nome completo dele era Maicon Souza Bispo e, 10 dias depois de ela ser presa, ele apareceu morto. Respondeu que trabalha no Paraíso, como supervisora, e está registrada há um ano e um mês, na empresa Aragon Marketing.

Pelo que se depreende dos autos havia uma denúncia anônima, em princípio contra um indivíduo chamado Maicon, e com base nessas informações, agentes da polícia civil se dirigiram ao local, que supostamente estaria com a porta aberta, onde efetuaram a apreensão de drogas, balanças e documentos. Partindo-se desses documentos encontrados, as investigações levaram ao nome da acusada, LAIS, e a um segundo endereço, para o qual a polícia se dirigiu munida de um mandado de busca e apreensão, realizando a apreensão de mais entorpecentes e de matérias-primas destinadas à preparação de drogas.

Sem avançar no mérito das questões relacionadas à autoria, verifica-se que os policiais efetuaram uma ação precipitada, uma vez que, para que houvesse a devida apreensão das drogas naquele primeiro imóvel, os policiais, com posse da informação prévia da existência de conduta ilícita naquele local, deveriam ter a devida autorização de ingresso por meio de um mandado de busca e apreensão, cautela que se observou somente na entrada à segunda residência. Não foi o que aconteceu. Os policiais informaram que foram ao local, uma vila com várias portas, onde revistaram alguns imóveis, com o consentimento de seus respectivos moradores, e uma das casas estaria com a porta aberta, da onde estaria saindo um forte odor e onde entraram encontraram as drogas, objetos, bem como documentos com os quais, por meio de investigações, levaram ao segundo imóvel. Encontrar a porta aberta em uma residência não dá respaldo para que a polícia invada o domicílio. O fato é que os policiais entraram no imóvel onde não se permitia o ingresso sem autorização. Foi esse o tipo de situação que levou o Superior Tribunal de Justiça a tomar a decisão recente contra violação de domicílio.

Nesse sentido, o ingresso dos policiais naquele primeiro imóvel sem autorização judicial ou sem a prova do consentimento do morador, torna ilegal tudo que foi encontrado e, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são nulas todas as provas derivadas do encontro das drogas, em que pese a busca e apreensão na segunda casa ter sido realizada com o devido mandado, não sobrando, portanto, mais nada que incrimine a ré.

Nesse sentido, já decidiu o referido Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg

no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir:

"1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições

legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corrê.

(STJ. HC: 616.584 - RS. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado no dia 30 de março de 2021) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período

noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c)

deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo



civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action"). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ. HC: ° 598.051 – SP. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado no dia 02 de março de 2021.)

Portanto, de rigor, o reconhecimento da ilicitude das provas localizadas dentro dos imóveis, já que obtidas por meio de invasão de domicílio, com a conseqüente absolvição da acusada por ausência da materialidade do crime de tráfico.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por conseqüência, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ABSOLVO a ré LAIS GONÇALVES PEREIRA (RG: 38680225) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput e §1º, inciso I, ambos da Lei n 11.343/06, combinados com o art. 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Em relação ao veículo apreendido, em que pese a absolvição da ré, verifica-se que não era da sua propriedade e que nem houve sequer interesse de restituição por parte de algum terceiro de boa-fé. Ademais, mesmo que comprovada a propriedade, nota-se que o carro era utilizado para a prática do tráfico, uma vez que parte dos

entorpecentes foram localizados em seu interior. Desta forma, decreto o perdimento do bem em favor da União, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Comunique à SENAD, inclusive reiterando-se o ofício de fls. 288/289, diante da representação da autoridade policial de fls. 270/273 e 290/293.

Quanto aos demais objetos e documentos, considerando que não mais interessam à persecução penal, autorizo a restituição ao legítimo proprietário, desde que comprovada adequadamente esta condição, com as cautelas devidas, procedendo-se, se o caso, na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA